

1503141-43.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS RAFAEL RODRIGUES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CARLOS RAFAEL RODRIGUES, conhecido como CACÁ, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 29 de setembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503141-43.2021.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503141-43.2021.8.26.0510 - 2021/000645

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS RAFAEL RODRIGUES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CARLOS RAFAEL RODRIGUES, conhecido como CACÁ, qualificado no inquérito, foi

denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 15:20 horas, na Avenida São Paulo, nº 135, Jardim Paulista, no município de Santa Gertrudes, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardava e tinha em depósito 44 (quarenta e quatro) microtubos de cocaína, totalizando aproximadamente 29 gramas, e 03 (três) porções de maconha, totalizando aproximadamente 10 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11, auto de constatação preliminar de fls. 12/13, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de apetrechos para preparação e acondicionamento de entorpecentes.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 15 de fevereiro de 2022. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ainda ser agravada por conta da recidiva, com o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, e fixação de regime prisional inicial fechado, incidindo, por fim, a pena de perdimento sobre a quantia de R\$ 10,00 apreendida, porque decorrente da atividade ilícita.

Já a ilustre Defensora Pública, preliminarmente, sustentou assentada a materialidade do delito em prova ilícita, decorrente a apreensão do entorpecente de busca realizada ilegalmente pela Guarda Municipal, em circunstâncias não autorizadas pelo artigo 144, §8º, da Constituição Federal, a determinar a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos II, do Código de Processo Penal. No mérito, entendendo insuficiente a prova produzida, pelas razões que cuidou em expor, pugnou também pela absolvição, aqui nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Em caso de acolhimento da pretensão acusatória, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que não configurada a recidiva, não sendo, caso contrário, específica, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, facultando-se a interposição de recurso em liberdade. Por fim, requereu a restituição dos valores apreendidos em poder do acusado.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardava e tinha em depósito o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 93/94, com resultado positivo para cocaína, identificando-se também em parte da substância apreendida o elemento tetraidrocanabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha.

Sustenta-se que a materialidade estaria assentada em prova ilícita, assim porque decorrente a apreensão do entorpecente de busca realizada ilegalmente por Guarda Municipal, em circunstâncias não autorizadas pelo que delineado no artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

Não se ignora, até mesmo em função da recorrência desta controvérsia, que a segurança pública, voltada à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas, é exercida pelas Polícias Militares e Cíveis, estabelecida pela Constituição Federal a possibilidade de criação, pelos Municípios da Federação, de Guardas Municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

E a Lei Complementar n. 13.022/14, destinada a regulamentar a atividade da Guarda Municipal, nos limites postos pelo artigo 144, §8º, da Constituição Federal, não obstante objeções de inconstitucionalidade, procurou atribuir àquela corporação papel mais ajustado às adversidades da atualidade, conferindo-lhe a possibilidade

de certa coadjuvância ou apoio na promoção da ordem e da segurança pública, consideradas em sentido mais amplo, sem invasão das competências das Polícias Civil e Militar.

E foi o exercício desta atividade de cooperação em proveito da segurança pública que marcou a atuação do Guarda Municipal que realizou a apreensão do entorpecente, escondido que estava, dentro de um cano de água pluvial, agindo em apoio de investigador de polícia que apurava na ocasião a imputação ao acusado da prática do delito de tráfico de entorpecentes, atuando em conjunto, de tal modo que não se verifica a apontada ilicitude de modo a macular, por derivação a materialidade do delito.

E a autoria irrogada ao acusado foi suficientemente evidenciada.

Ouvido em juízo, o acusado negou a prática do delito afirmando que na ocasião dos fatos, pouco antes de sua abordagem, ingressou em um bar, que não lhe pertence, tampouco por lá exerce atividade comercial, com o propósito de comprar um refrigerante, negando tivesse naquele local mantido contato com qualquer usuário de entorpecente, como também se deslocado em momento algum para junto de um cano de água pluvial nas proximidades daquele estabelecimento, observando que os valores apreendidos em seu poder decorriam de sua atividade laborativa como carpinteiro. Todavia a versão deduzida pelo acusado foi contrariada pela prova produzida. De fato, o investigador de polícia Valcenir Calefi, reiterando em juízo o que exposto contemporaneamente aos fatos, afirmou que na ocasião, em razão de informações sobre a ocorrência de tráfico de entorpecente em um estabelecimento comercial, denominado de "Bar do Cacá", chegaram a abordar naquele local, dias antes, um indivíduo que procurava dispensar no banheiro algumas porções de cocaína, que posteriormente informou ter-las adquirido naquele estabelecimento, pertencente ao acusado. Em função desta apreensão, a amparar a denúncia que fora inicialmente recebida, iniciaram um trabalho de campo e constataram que, em determinado momento, o acusado manteve contato com um usuário, que adentra àquele bar, e depois deixa o local para se aproximar na via pública de um cano de água pluvial, junto ao qual se agacha, para depois retornar ao local de origem e manter novo contato com aquele usuário. Diante destas circunstâncias, com o apoio da Polícia Militar, foi o acusado abordado, com ele sendo apreendida a quantia de trezentos e sessenta e quatro reais em dinheiro. Abordado também o referido usuário (Jonathan), este admitiu que acabara de comprar de um indivíduo, que apontou como sendo proprietário do bar, uma porção de cocaína, que já fora consumida no banheiro, pela quantia de dez reais. Em seguida, no local para onde se dirigiu anteriormente o acusado, em um cano de água pluvial, foi localizado um estojo contendo em seu interior quarenta e quatro porções de cocaína e três de maconha, tendo-se tido o cuidado de fotografar o acusado no momento em que ele se encontrava neste local (fls. 20).

No mesmo sentido o guarda municipal Claudio Roberto, afirmando que à época dos fatos, atuando em cooperação na Delegacia de Polícia de Santa Gertrudes, acompanhou o trabalho do investigador de polícia Valcenir Calefi, com vistas à apuração de tráfico de entorpecentes que estaria sendo realizado em um estabelecimento comercial denominado "Bar do Cacá", local onde se chegou a apreender algumas porções de cocaína dispensadas por usuário por lá abordado dias antes, tendo este informalmente dito que adquirira o entorpecente naquele mesmo estabelecimento.

Posteriormente, segundo ainda o exposto, realizou-se um trabalho de campo, com observação do local, quando então constatou-se a movimentação do acusado, tal como indicada na inicial, fornecendo entorpecente a um outro usuário, tendo sido possível verificar que ele guardava a droga no interior de um cano de água pluvial, nas proximidades. Nesta ocasião o usuário foi também abordado, confirmando ter adquirido o entorpecente do acusado, proprietário do bar.

Como se tem consagrado, à míngua de qualquer elemento probatório que indique algum abuso, não se pode presumir que agentes públicos estivessem animados do propósito de incriminar indevidamente o acusado. Sobre isto: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à

justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Além do depoimento do Policial Civil e do Guarda Municipal, conquanto somente na fase inquisitória, mas contando com o amparo do plexo probatório, o usuário abordado na ocasião dos fatos confirmou perante a d. Autoridade Policial que realmente foi informado à época que poderia adquirir cocaína no referido bar, lá mantendo contato com um indivíduo, que estava com uma camiseta cavada, o qual se prontificou a vender-lhe o entorpecente, tendo então deixado o estabelecimento e se dirigido a um cano de água pluvial, onde apanhou a droga, que posteriormente lhe entregou pela quantia de dez reais (fls.8).

Além disto, cuidou-se em fotografar a ação do acusado, identificado pelo Investigador de Polícia como sendo aquele indivíduo apontado pelo usuário, que vestia uma camiseta cavada, no momento mesmo em que se agachava junto ao cano de água pluvial, movimento este que possibilitou a localização do entorpecente (fls. 19/21).

Acresça-se que com o acusado foi apreendida a quantia de trezentos e sessenta e quatro reais em dinheiro, justificada a origem tão somente na alegação de que exercia atividade laborativa de carpinteiro, mas sem que a acompanhasse demonstração idônea, tendo observado, ademais que no dia dos fatos não se encontrava exercendo seu mister.

Deste modo, as circunstâncias indicadas, revelando a posse do entorpecente, como também a sua destinação mercantil, possibilitam juízo de convicção seguro sobre a imputação inicial, sendo incontornável o acolhimento da pretensão acusatória.

Por fim, não obstante a apreensão de valores em poder do acusado, cuja origem não foi evidenciada, comprovou-se que R\$ 10,00 decorreram efetivamente da venda de uma porção de cocaína ao usuário acima referido, devendo incidir sobre esta quantia a pena de perdimento.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, embora de naturezas diversas, possível seja a pena-base fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena-base deve ser agravada, entretanto, em 1/6 (um sexto), por conta da recidiva, demonstrada às fls. 26/27, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Por fim, diante do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, a recidiva também afasta objetivamente a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ressaltando-se, ainda, que o trabalho de investigação realizado decorreu de notícia de que o comércio ilícito já se desenvolvia no estabelecimento comercial, explorado pelo acusado, de forma continuada, indicando dedicação à atividade criminosa, incompatível com "tráfico

privilegiado".

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso I, do Código Penal, CONDENO o acusado CARLOS RAFAEL RODRIGUES à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato, operando-se ainda o perdimento da quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, deve ser considerada a recidiva e também a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispondo o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interdita a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descuidar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras. Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução

provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1). E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inocorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA